

3002047-13.2013.8.26.0430
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Dano ao Erário
Magistrado: LUAN CASAGRANDE
Comarca: Paulo de Faria
Foro: Foro de Paulo de Faria
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos."

(PAZZAGLINI FILHO, M; ELIAS ROSA, M. F. e FAZZIO JÚNIOR, W. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996).

A expressão designa, tecnicamente, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3002047-13.2013.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3002047-13.2013.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Civil Pública - Dano ao Erário

Requerente:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Requerido:

Luiz Desidério Borges e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa em face de LUIZ DESIDÉRIO BORGES; OLIVIO SCAMATTI; EDSON SCAMATTI; PEDRO SCAMATTU FILHO; DORIVAL REMEDI SCAMATTI; MAURO ANDRE SCAMATTI; LUIZ CARLOS SELLER; MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI; OSVALDO FERREIRA FILHO; CARLOS GILBERTO ZANATA; EDSON CESAR DE SOUZA; VALDOVIR GONÇALVES; CIRO SPADÁCIO; CIRO SPADÁCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA; ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA; SCAMVIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA, todos qualificados na exordial.

Historiou que através da "Operação Fratelli" foi desmantelada uma organização criminoso que operava em fraudes de licitações, com desvios de emendas parlamentares. Afirmou que as investigações apontaram pela existência de uma quadrilha organizada que praticava condutas ilícitas e ímproba com apropriação de

recursos financeiros repassados pela União e Estado, via convênio e outros instrumentos congêneres, com o fito de recapeamento asfáltico. Asseverou que os recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares eram direcionados aos Municípios e, na sequência, o grupo criminoso ocupava-se de procurar gestores municipais – através de lobistas – para informar-lhes da existência de recursos e da exigência da destinação do recurso para empresas previamente escolhidas para a participação da licitação. Posteriormente, mediante prévia concordância dos gestores públicos eram montados procedimentos licitatórios manipulados, visando à adjudicação do objeto respectivo em favor de alguma das empresas constituídas para a consecução da empreitada criminosa. Por fim, os recursos públicos eram recebidos e apropriados serviam para os interesses do grupo criminoso, inclusive, para pagamentos de propinas a agentes políticos e públicos, com o fim de disseminar as fraudes por inúmeros municípios e para o atendimento de interesses outros do grupo criminoso. Afirmou que a organização criminosa era chefiada pelo Grupo Scamatti, mediante a constituição de inúmeras empresas, todas vinculadas aos réus Dorival, Pedro, Olivio, Mauro e Edson. Relatou que foram observados contratos com valores em torno de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), distribuídos entre as empresas SCAMVIAS Construções e Empreendimentos Ltda, ULTRAPAV Engenharia de Pavimentos Ltda, CIRO SPADACIO Engenharia e Construção Ltda e DEMOP Participações Ltda. Vindicou pela decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos. Pugnou pela procedência da ação, com a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa descrita no art. 11, cpaut, e inciso I, da Lei nº 8.429/92. Anexou documentos (fls. 110-282).

Foi deferida a tutela cautelar vindicada (fls.283-286).

Devidamente notificados, os requeridos ULTRAPAV engenharia, Carlos Gilberto Zanata e Edson Cesar de Souza, ofertaram manifestação prévia (fls. 429-443), Ciro Spadacio (fls. 501-511), Scamatti & Seller (fls. 589-670), Luiz Desidério (fls. 717-723). O Ministério Público pleiteou a juntada de laudo pericial (fls. 729-750).

Restou certificado a inércia do Município de Paulo de Faria à oferta de defesa preliminar (fl. 755).

Sobreveio manifestação do Município de Paulo de Faria (fls. 803-805).

Aportou aos autos manifestação do Ministério Público pleiteando o recebimento da exordial (fl. 819).

Restou recebida a petição inicial e determinado a citação dos demandados (fl. 821).

Citados, os requeridos ofertaram contestação (fls. 903-961, 1.003-1.326, 1.374-1.452).

Aportou aos autos assento de óbito de Luiz Desidério (fls. 996-998).

Foi deferida a habilitação dos sucessores (fl. 1.458).

O ilustre representante do Parquet ofertou réplica (fls. 1.477-1.485).

Adveio contestação do espólio de Luiz Desiderio (fls. 1.486-1.500).

Instadas as partes acerca do interesse na produção probatória, as partes manifestaram-se (fls. 1.627-1.663, 1.667-1.674, 1.677-1.705, 1.706-1.707, 1.708-1.715, 1.716-1.737, 1.744-1.745, 1.746-1.747, 1.750-1.753).

Realizada a solenidade de instrução e julgamento, na qual foram inquiridas 01 (uma) testemunha arrolada pela parte requerida (fls. 1.789-1.793).

Foi deferido o pedido de produção de prova emprestada (fl. 1.828).

Sobreveio manifestação com documentos (fls. 1.831-1.852).

Aportou manifestação dos réus pela desistência da inquirição de 01 testemunha (fl. 1.858).

Acostado aos autos documentos emprestados pela Comarca de Fernandópolis (fls. 1.922-1.964).

Restou declarada encerrada a instrução e facultado às partes prazo para apresentação de alegações finais (fl. 1.970).

O Ministério Público pleiteou pela improcedência da demanda, em face da ausência de provas (fls. 1.980-2.010).

Aportou aos autos alegações finais pelos requeridos (fls. 2.016-2.019, 2.020, 2.021-2.031, 2.032, 2.033-2.034).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Trata-se de ação civil pública aforada pelo Ministério Público, com fundamento no art. 5º da Lei nº 7.347/85 e art. 25, IV, alínea "b", da Lei nº 8.625/93, devido a suposta prática de ato de improbidade administrativa dos réus.

Inicialmente, cumpre destacar que sendo o órgão ministerial agente imbuído na efetiva fiscalização do cumprimento dos mandamentos constitucionais, é função institucional deste a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para proteção tanto do patrimônio público e social, quanto do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, consoante o disposto no art. 129, III, da Carta Magna:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

A Ação Civil Pública como instrumento processual capaz de dar efetiva proteção aos direitos difusos, entendidos estes como sendo aqueles pertencentes à toda a coletividade, traz em seu bojo a essencialidade de se preservar e reprimir os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social e, principalmente, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

"O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje não é tanto de justificá-los mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político" (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 10ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.72).

Na intenção de se construir uma perfeita compreensão do atual fenômeno da coletivização do processo, resultado da necessidade de se conferir tutela coletiva aos interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tem-se que se ter em mente a necessidade de envolvimento anterior com as motivações de ordem histórica, social e econômica que terminaram por desencadear tal fenômeno. É essa a ideia exposta por Norberto Bobbio "é que a proteção destes últimos [direitos sociais] requer uma intervenção ativa do Estado, que não é requerida pela proteção dos direitos de liberdade." (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 10ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992).

Como é sabido, para a propositura de ação civil pública há de se perquirir acerca da representatividade adequada do autor para a proteção do direito coletivo 'latu sensu' em debate.

A representatividade adequada significa a relação que deverá existir entre aquele que pretende realizar a defesa e o direito coletivo que será defendido. Assim, com base no estudo das class action americanas, somente as pessoas, órgãos ou entes que possuem representatividade adequada são habilitados a agirem como legitimados ativos nas ações coletivas. Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior lecionam: "Primeiramente, verifica-se se há autorização legal para que determinado ente possa substituir os titulares coletivos do direito afirmado e conduzir o processo coletivo. A seguir, o juiz faz o controle in concreto da adequação da legitimidade para aferir, sempre motivadamente se estão presentes os elementos que asseguram a representatividade adequada dos direitos em tela." (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. Vol. 4. 5ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 211-212. A tendência é a consagração legislativa da possibilidade deste controle judicial).

O Brasil adotou a tese da representatividade adequada ope legis, ou seja, os legitimados para as ações coletivas são determinados previamente pela Lei. A condição de representante adequado é estabelecida pelo legislador. Nessa senda, traz consigo a norma de regência em seu art. 5º, inciso I, da Lei n. 7.347/85:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I - o Ministério Público;”

O dispositivo supra elencado está em consonância com a previsão contida no art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, que consagrou, segundo a melhor doutrina, a chamada representatividade adequada, teoria adotada nos Estados Unidos com as chamadas class action. Nesse sentido:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente:
I - o Ministério Público,

Cuida-se de uma verdadeira presunção de que os legitimados estabelecidos pela lei são representantes adequados a defenderem os interesses coletivos. Flávia Hellmeister Clito Fornaciari, em tese sobre o tema, conceituou a representatividade adequada como “[...] uma qualidade apresentada pelo representante que atuará em nome da sociedade ou do grupo na defesa de interesses de ordem coletiva [...]” (FORNACIARI, Flávia Hellmeister Clito. Representatividade adequada nos processos coletivos. Tese de Doutorado orientada pela professora Ada Pellegrini Grinover a apresentada à Faculdade de Direito da USP. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2010, p.50). Eurico Ferraresi leciona que: “O requisito da representatividade adequada tem origem no sistema da common law, apresentando-se como uma decorrência natural da proteção do due process. Os países do common law exigem que o autor coletivo represente adequadamente os interesses do grupo, diante da ausência dos interessados não identificados e que sequer serão ouvidos em juízo. Por este motivo é que os tribunais redobram a atenção no momento de verificarem a capacidade do autor coletivo.” (FERRARESI, Eurico. Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos processuais coletivos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.112. Cf. MULLENIX, Linda S. New trends in standing and res judicata in collective suits. General Report – Common law. In: Direito processual comparado, XIII World Congress of Procedural Law, Salvador, 16-22 set. 2007; Rio de Janeiro: Forense, 2007. A autora coloca o conceito de representatividade nos seguintes termos: “intricately related to the protection of the due process interests of absent class members. Because the class representatives are representing the interests of absent class members, the representatives are guardians and fiduciaries for the class interests”).

A representatividade adequada funciona como um instituto legitimador da tutela jurisdicional coletiva, pois a decisão alcançará quem não participou do processo, portanto, a representação deve ter sido adequada.

No caso em apreço, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública para buscar o ressarcimento pecuniário em prol do Erário Público, bem como para ver efetivada as sanções por improbidade no exercício do múnus público.

I – DO CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Consoante preconiza o art. 12 da Lei nº 8.429/92, as sanções previstas nessa norma independem daquelas apostas no âmbito criminal e administrativo:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:

Ademais, na esfera constitucional, nossa Carta Magna prescreve em seu art. 37, § 4º que as penalidades impostas em sede de apuração de atos de improbidade administrativas, independem da ação penal cabível:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao

seguinte: (...)

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Nesse ínterim, trago à baila os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro quanto à abordagem ora em debate: "A primeira observação a fazer é no sentido de que um ato de improbidade administrativa pode corresponder a um ilícito penal, se puder ser enquadrado em crime definido no Código Penal ou em sua legislação complementar. É o que decorre da própria redação do dispositivo constitucional, quando, depois de indicar as medidas sancionatórias cabíveis, acrescenta que a lei estabelecerá sua forma e gradação "sem prejuízo da ação penal cabível". Por outras palavras, pode ocorrer que algum dos ilícitos definidos em lei como ato de improbidade corresponda a um crime definido em lei, por exemplo, a um dos crimes contra a Administração Pública previstos no capítulo pertinente do Código Penal ou a um dos crimes de responsabilidade definidos na legislação específica sobre a matéria. Isso permite concluir que: (a) o ato de improbidade, em si, não constitui crime, mas pode corresponder também a um crime definido em lei: (b) as sanções indicadas no art. 37, § 4º, da Constituição não têm a natureza de sanções penais, porque, se tivessem, não se justificaria a ressalva contida na parte final do dispositivo, quando admite a aplicação das medidas sancionatórias nele indicadas "sem prejuízo da ação penal cabível"; (c) se o ato de improbidade corresponder também a um crime, a apuração da improbidade pela ação cabível será concomitante com o processo criminal. (...) A natureza das medidas previstas no dispositivo constitucional está a indicar que a improbidade administrativa, embora possa ter consequências na esfera criminal, com a concomitante instauração de processo criminal (se for o caso) e na esfera administrativa (com a perda da função pública e a instauração de processo administrativo concomitante) caracteriza um ilícito de natureza civil e política, porque pode implicar a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento dos danos causados ao erário."

Grifos da autora. Prossegue a doutrinadora: "Consoante já assinalado, os atos de improbidade estão definidos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. Muitos deles podem corresponder a crimes definidos na legislação penal e a infrações administrativas definidas nos Estatutos dos Servidores Públicos. Nesse caso, nada impede a instauração de processos nas três instâncias, administrativa, civil e criminal. A primeira vai apurar o ilícito administrativo segundo as normas estabelecidas no Estatuto funcional; a segunda vai apurar a improbidade administrativa e aplicar as sanções previstas na Lei nº 8.429/92; e a terceira vai apurar o ilícito penal segundo as normas do Código de Processo Penal" (In Direito Administrativo, 22ª ed. São Paulo. Atlas, 2009, pp. 810-811 e 813).

Desse modo, conclui-se que a Lei de Improbidade Administrativa é de natureza civil, e não penal, como erroneamente se pensa. Porém, tal preposição não se esgota em seu caráter civil, pois, além das penas pecuniárias (perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento dos danos causados ao erário e multa), também há penas de caráter administrativo (perda da função pública e proibição de contratar com a Administração Pública e de receber benefícios fiscais e creditícios) e de caráter político (suspensão dos direitos políticos).

Portanto, quanto ao objeto, a lei tem natureza híbrida (civil, administrativa e política), quanto à competência, sua natureza é somente civil, devendo ser julgada no competente juízo cível.

Assim sendo, não há que se falar na inviabilidade do processamento da ação civil concomitante ao processo penal acusatório, na medida em que as sanções buscadas pelas espécies são distintas e não configuram o chamado "bis in idem."

II - DO MÉRITO

Antes de adentrar efetivamente na questão controvertida nos autos, cabe fazer uma análise principiológica dos elementos que circundam os fins buscados pela

Administração Pública no âmbito de sua atuação.

Consabido que a Administração Pública deve estar engajada em princípios e normas que visem o bem comum de uma determinada camada da população escorada na figura de seus administradores. Como bem elucida Hely Lopes Meirelles: "Os fins da administração pública resumem-se num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada. Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se afasta ou desvia, trai o mandato de que está investido, porque a comunidade não institui a Administração senão como meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e imoral será todo ato administrativo que não for praticado no interesse da coletividade. (...) No desempenho dos encargos administrativos o agente do Poder Público não tem a liberdade de procurar outro objetivo, ou de dar fim diverso do prescrito em lei para a atividade. Não pode, assim, deixar de cumprir os deveres que a lei lhe impõe, nem renunciar a qualquer parcela dos poderes e prerrogativas que lhe são conferidos. Isso porque os deveres, poderes e prerrogativas não lhe são outorgados em consideração pessoal, mas sim para serem utilizados em benefício da comunidade administrada. Descumpri-los ou renunciá-los equivalerá a desconsiderar a incumbência que aceitou ao empossar-se no cargo ou função pública. (...) Em última análise, os fins da Administração consubstanciam-se na defesa do interesse público, assim entendidas aquelas aspirações ou vantagens lícitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou por uma parcela expressiva de seus membros. O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse público configura desvio de finalidade." (In Direito Administrativo Brasileiro, 35^a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 87-88). Dessa forma, o administrador e os particulares que busquem manter vínculo jurídico especial para com a coisa pública têm a obrigação de conduzir sua atuação dentre outros sob os princípios da legalidade, moralidade e probidade, consoante preconiza o Mandamento Constitucional do art. 37, caput:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Porquanto, sopesando os princípios que devem embasar os atos praticados na Administração Pública, não basta apenas ao agente público agir dentro da legalidade, obedecendo estritamente a norma legislativa, há que se temperar se dos seus atos pode-se extrair o agir ético, honesto, de boa-fé, capaz de assegurar a boa administração. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "o princípio da moralidade exige da Administração Pública comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade" (In Direito Administrativo, 22^a ed. São Paulo. Atlas, 2009, p. 358).

Constituem, a bem da verdade, os fundamentos da Administração Pública, de modo que o desvio desses princípios ocasiona a severa sanção por ausência de probidade, lealdade e honestidade. De fato, a Administração Pública, como envolta aos princípios da moralidade, legalidade, eficiência, publicidade, impessoalidade e finalidade, imperializa a necessidade premente dos administradores em ministrar seus atos no alcance do bem comum, mediante a melhor conveniência pública. Como assevera Marcelo Figueiredo "Entendemos que se pretendeu afirmar que a lei pune tão somente o dano material à administração, como também, qualquer sorte de lesão ou violação à moralidade administrativa, havendo ou não prejuízo no sentido econômico" (Apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 22^a ed. São Paulo. Atlas, 2009, p. 822).

Pois bem, a Administração Pública é pautada por regras e princípios, das quais sobre esses padrões é que deverão se engajar todos os atos e atividades praticadas por seus administradores e aos particulares que buscarem manter um vínculo de sujeição especial para com a coisa pública.

Em análise apertada, cumpre esclarecer que ao administrador é assegurado o poder de gerir os bens públicos de toda uma coletividade, de modo que a gerência pública

deve-se pautar pelo uso legal do poder que lhe é atribuído, na busca do bem comum. Segundo Diógenes Gasparini “o uso normal do poder significa empregá-lo segundo as normas legais, a moral, da instituição a finalidade do ato e as exigências do interesse público” (GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 142).

Nesse norte, cumpre destacar que o uso da máquina pública para a realização de atos destoante das bases que regem a administração causa o desvio de finalidade com o excesso de poder que foi atribuído ao administrador, ocasionando assim, a sua ilegalidade.

No excesso, a Administração vai além do permitido, estendendo direitos, deveres e obrigações, favorecendo interesses ou retirando faculdades, inobservando a norma legal e as condições extrínsecas nela prescritas (SOBRINHO, Manoel de Oliveira Franco apud GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 145).

Por conseguinte, a improbidade administrativa configura-se como sendo um dos maiores males envolvendo a máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a implementação de um maior controle social. O conceito de improbidade é bem mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si. É o contrário de probidade, que significa qualidade de proba, integridade de caráter, honradez. Logo, improbidade é o mesmo que desonestidade, mau caráter, falta de probidade. Doutrinariamente a Improbidade Administrativa pode ser definida como sendo: “A corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano) revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo “tráfico de influência” nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos.”

(PAZZAGLINI FILHO, M; ELIAS ROSA, M. F. e FAZZIO JÚNIOR, W. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996).

A expressão designa, tecnicamente, a chamada “corrupção administrativa”, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública de seus fundamentos básicos de moralidade, afrontando os princípios da ordem jurídica do Estado de Direito. Nessa senda, consubstancia-se que na Administração Pública não há vontade nem liberdade pessoal, devendo o administrador obedecer estritamente aos mandamentos legais - “dever fazer”, sob pena de incorrer em ilegalidade. Nesse aspecto, leciona Hely Lopes Meirelles: “As leis administrativas, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais poderes, conferidos à Administração Pública para serem utilizados em benefício da coletividade, não podem ser renunciados ou descumpridos pelo Administrador sem ofensa ao bem comum, que é o supremo e único objetivo de toda ação administrativa.” Prossegue o doutrinador: “Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública.” (In Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 89).

Dessa forma os atos perpetrados pelos administradores ao arrepio da norma jurídica se revestem de ilegalidades e, por conseguinte, em havendo sido realizados em proveito próprio e/ou alheio tornam-se improbos, devendo, pois, sofrer a intervenção judicial para garantia dos interesses públicos:

Lei nº 4.717/65 - Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

- b) vício de forma;
- c) ilegalidade do objeto;
- e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

- a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
- b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
- c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
- e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 22ª ed. São Paulo. Atlas, 2009, p. 823).

Quanto à existência de dolo ou culpa, há de se temperar que na lei de improbidade administrativa, necessário se faz a aferição da existência de má-fé por parte do agente causador do dano, configurando um comportamento desonesto.

No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 22ª ed. São Paulo. Atlas, 2009, p. 82).

Nesse sentido, houve expressa alteração legislativa no código de normas da improbidade – Lei nº 8.429/92, a fim de assentar a necessidade da comprovação do agir doloso dos agentes públicos e terceiros que causarem danos ao erário:

Art. 1º (...)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Por tudo isso, imperioso revelar que no caso concreto, a produção da prova material restou prejudicada em razão da decisão profligada pela Suprema Corte quando do julgamento do HC nº 129.646, que deliberou pela anulação de toda a prova angariada no procedimento investigativo que deu ensejo a presente demanda, vejamos:

EMENTA: “HABEAS CORPUS” – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NECESSIDADE DE A DECISÃO QUE A AUTORIZA POSSUIR FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA, SOB PENA DE NULIDADE – IMPRESTABILIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE, DESPROVIDO DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA, RESUME-SE A FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS CONSUBSTANCIADAS EM TEXTOS PADRONIZADOS REVESTIDOS DE CONTEÚDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PROBANTE DAS INFORMAÇÕES RESULTANTES DE PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADAS POR DECISÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DA ILICITUDE DA PROVA: TEMA IMPREGNADO DE ALTO RELEVO CONSTITUCIONAL – DIREITO FUNDAMENTAL DE QUALQUER PESSOA DE NÃO SER INVESTIGADA, ACUSADA, PROCESSADA OU CONDENADA COM BASE EM PROVAS ILÍCITAS (HC 93.050/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO – RHC 90.376/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – INADMISSIBILIDADE DA SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER – DISCUSSÃO EM TORNO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO (“FRUITS OF THE POISONOUS TREE”) – DOUTRINA – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 129646 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma,

julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10-2020)

Dessa forma, consoante bem lançado alegações finais ministerial, subsistindo declaração de ilicitude da prova produzida que deu ensejo ao aforamento da demanda, tem-se que o conjunto probatório restou enfraquecido e insuficiente para o édito condenatório. Embora os indícios constantes dos autos apontavam pela prática de atos lesivos ao Erário Público, não se pode embasar uma certeza capaz de acolher a pretensão inaugural. Em assim, sendo, ausente prova segura que justifique o acolhimento do pedido inicial, o único caminho a ser trilhado é o da improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a presente Ação Civil Pública aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de SUCESSÃO DE LUIZ DESIDÉRIO BORGES; OLIVIO SCAMATTI; EDSON SCAMATTI; PEDRO SCAMATTU FILHO; DORIVAL REMEDI SCAMATTI; MAURO ANDRE SCAMATTI; LUIZ CARLOS SELLER; MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI; OSVALDO FERREIRA FILHO; CARLOS GILBERTO ZANATA; EDSON CESAR DE SOUZA; VALDOVIR GONÇALVES; CIRO SPADÁCIO; CIRO SPADÁCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA; ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA; SCAMVIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais, em face do contido no art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Em subsistindo indisponibilidades de bens, proceda-se a z. Serventia ao seu levantamento.

Comandos finais

1- Decorrido o prazo recursal ou havendo renúncia das partes a este, certifique-se o trânsito em julgado e intímese as partes, cabendo ao interessado, sendo o caso, instaurar o respectivo cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento (art. 1.286, §6º, das NSCGJ).

2- Após, proceda-se à conferência do recolhimento integral de todas as custas processuais devidas; à consulta da validade e da veracidade das guias DARE-SP, oportunidade em que deve ser realizada a vinculação do documento ao número do processo para impossibilitar a reutilização; bem como à queima das guias no Portal de Custas, certificando-se nos autos, de acordo com o Comunicado CG nº 136/2020 da egrégia Corregedoria Geral da Justiça (arts. 1.093, §6º e 1.098, caput, das NSCGJ).

3- Caso haja custas processuais pendentes, intime-se o responsável para efetuar o pagamento no prazo de 60 dias, sob pena de extração de certidão para fins de inscrição na dívida ativa, nos termos do art. 1.098, §§1º e 2º, das NSCGJ.

4- Ainda, proceda-se à baixa nos alertas de pendências, à exclusão das tarjas insubsistentes e à remoção de cópias no subfluxo de processos e de documentos pendentes no subfluxo de documentos, se necessário com abertura de chamado ao setor de informática.

5- Por fim, archive-se com extinção e baixa definitiva, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado, observados os códigos de movimentação descritos no Comunicado CG 1789/17 (art. 184, parágrafo único, das NSCGJ).

6- Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, assegurada a contagem em dobro para o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, na forma dos arts. 180, 183 e 186 do CPC (art. 1.010, §1º do CPC).

7- Interposta apelação adesiva, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões na forma do item 6 (art. 1.010, §2º, do CPC).

8- Cumpridas as formalidades descritas acima, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as nossas homenagens, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, do CPC).

9- Com o retorno dos autos à origem, intímese as partes para cumprirem o v. acórdão, cabendo ao interessado, sendo o caso, instaurar o respectivo cumprimento

de sentença no prazo de 30 dias (art. 1.286, §6º, das NSCGJ). Após, archive-se, observadas as diretrizes descritas nos itens 2 a 5. Certifique-se o decurso de prazo quando não houver manifestação da pessoa intimada. Cumpra-se por simples ato ordinatório sempre que possível.
P.I.C.

Paulo de Faria, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA